Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

Conclusão

Aos 15/08/2019 08:58:22 foram estes autos conclusos ao Dr. Eduardo Magrinelli Júnior, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Naviraí-MS.

SENTENÇA

Vistos e examinados estes autos sob nº 0807989-97.2018.8.12.0029 de **AÇÃO Procedimento Comum Cível** em que é **Autor:** Ana Luiza Lima Moreira e **Réu:** Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Ana Luiza Lima Moreira, criança, representada pela genitora *Suelir Lima Xavier*, ambas qualificadas nos autos, move a presente **Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória** em desfavor do **Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Naviraí,** também qualificados, dizendo, em resumo, que necessita, com urgência, de leite especial denominado Nutren Júnior, na quantidade de 20 latas de 400g por mês, e que sua genitora não tem condições de adquiri-lo, uma vez que o custo mensal desse produto, na quantidade que necessita, representa um total de R$1.400,00. Afirma que possui paralisia cerebral e epilepsia de difícil controle, secundários à prematuridade e que a alimentação especial foi prescrita pelo médico que a acompanha. Diz que também não conseguiu obter a alimentação, administrativamente, dos Requeridos. Pede, ao final, que os Requeridos sejam compelidos a lhe fornecerem o leite especial descrito acima, enquanto houver a necessidade. Fez demais requerimentos de praxe e juntou documentos às f. 15-31.

Tutela provisória indeferida pela decisão de f. 37-39 mediante prévia consulta ao NAT (f. 33-36).

Todavia, em segunda instância, a decisão foi modificada (f. 201-219) com determinação de fornecimento do alimento especial à Requerente.

Citado, o Município apresentou contestação às f. 49-56, argumentando, em síntese, que o parecer do NAT foi negativo em relação à pretensão inicial, que não há risco iminente à vida da paciente e que não é mencionada contraindicação à dieta enteral artesanal; que não há provas nos autos acerca de restrição alimentar da Autora, que pode ser alimentada com dieta elaborada em domicílio; que o Município possui limitações orçamentárias e necessita executar políticas continuadas, não podendo ser obrigado a satisfazer a pretensão inicial, especialmente diante da não demonstração de sua imprescindibilidade. Pugnou pela improcedência do pedido e juntou documentos às f. 57-134.

O Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação às f. 163-170, onde arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, dizendo que a obrigação reclamada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 12/11/2019 às 11:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807989-97.2018.8.12.0029 e código rhJBqIFX.

é de responsabilidade do ente municipal; No mérito, argumentou que é possível a utilização de dieta comum pela Autora, como foi indicado pelo NAT. Em caso de condenação, manifestou pela impossibilidade de aplicação de multa cominatória e de fixação de honorários em face da fazenda pública estadual. Pediu a improcedência do pedido inicial.

A autora apresentou réplica às f. 180-200 e requereu a realização de estudo social em sua residência e juntada de outros documentos.

Os Requeridos opinaram pelo julgamento antecipado do mérito (f. 176 e 179).

É o relatório no essencial.

Decido.

<u>Preliminar</u>

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, é matéria já consolidada na jurisprudência, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo dúvida de que as três esferas da administração detêm, solidariamente, legitimidade para responder pelas demandas atinentes à saúde, pouco importando o estabelecimento de critérios de divisão de suas competências no âmbito administrativo. Nesse sentido, são os seguintes julgados:

> *"(...) O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.*
> *Precedentes do STJ. (...) [AgRg no REsp 1225222/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 05/12/2013]*
>
> *"(...) A CF/1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo passivo da demanda.(...)" [AgRg no REsp 690.483/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 06/06/2005, p. 208]*

Aliás, o tema já está resolvido inclusive perante o Supremo Tribunal Federal:

> *AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 12/11/2019 às 11:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807989-97.2018.8.12.0029 e código rhJBqIFX.

> *RIO GRANDE DO SUL.* ***OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO*** *EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO. I − O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN,* ***fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária****. II − Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio. III - Agravo regimental improvido (AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010, DJe-020 DIVULG 31-01-2011 PUBLIC 01-02-2011 EMENT VOL-02454-13 PP-03289)* - original sem grifos

Dessarte, ante o firme entendimento jurisprudencial sobre a matéria, totalmente despiciendas maiores ilações, devendo ser afastada, sem outras delongas, a preliminar arguida.

Mérito

Conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas, o que, aliás, sequer foi requerido por alguma das partes.

O ordenamento jurídico brasileiro tutela o direito à saúde, determinando o artigo 196 da Constituição Federal que:

> "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Por sua vez, a Lei n.º 8.080, de 19/9/90, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estatui em seu artigo 2.º que "A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício." E, no artigo 7.º, que "As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde − SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I − universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II − integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; IX − descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;".

Basta o dispositivo previsto no texto constitucional citado para se chegar à conclusão de que se deve garantir o direito de todos, independentemente da condição financeira, à saúde. As normas infraconstitucionais, que procuram dar efeito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 12/11/2019 às 11:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807989-97.2018.8.12.0029 e código rhJBqIFX.

integrador ao texto constitucional, seriam até despiciendas se existisse a consciência, por parte de todos os responsáveis pelas administrações dos entes federados, de que a Constituição Federal não é puramente analítica. A Constituição, com sua força normativa, constitui energia que deve influir na realidade. O dever da Administração de adquirir o necessário ao atendimento de pessoas doentes, imposto pela Constituição, não pode ser inviabilizado enventualmente através de entraves burocráticos e questiúnculas referentes à competência deste ou daquele órgão para distribuição. A distribuição de competências entre os entes federados é firmada para melhor servir aos cidadãos e não para aumentar seus sofrimentos e angústias, motivo pelo qual há solidariedade entre eles.

A edição da Lei nº 12.401/2011, em que pese sua importância e necessidade de respeito, não pode implicar em preterimento dos direitos do cidadão. A lei deve respeito à Constituição Federal e o Poder Judiciário é o garante das promessas do constituinte. Assim, como a Carta Magna traz a promessa de ampla proteção no campo da saúde, não pode o ente público se esquivar da sua obrigação, até porque estamos diante de tema que perpassa pela dignidade da pessoa humana. O Tribunal de Justiça do Estado, a respeito do tema já decidiu:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 12.401/2011 – PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE PREVALECE SOBRE LEI, PORTARIA OU ATO NORMATIVO INFERIOR – DIREITO À SAÚDE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – MEDICAMENTO EXPERIMENTAL – SEM RELEVÂNCIA DESDE QUE INDICADO POR MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar no reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 12.401/2011, posto que já é pacífico o entendimento de que a garantia ao acesso igualitário das pessoas saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal está acima de qualquer lei, portaria ou ato normativo inferior. Uma vez sopesados os interesses de ambas as partes, verifica-se que o princípio da integralidade que é fundamento do interesse do recorrente, não deve prevalecer sobre o princípio basilar da pretensão do recorrido, que é o da dignidade da pessoa humana. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Já é sedimentado o entendimento de que, se beneficiar o paciente, o médico pode utilizar um medicamento para finalidades diversas das indicadas, mesmo que em fase experimental. (TJMS, Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, agravo nº 2012.015841-8, julgado em 17.07.2012).*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 12/11/2019 às 11:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807989-97.2018.8.12.0029 e código rhJBqIFX.

É inequívoca a responsabilidade dos Réus de fornecerem assistência à saúde a quem dela necessitar, o que inclui o oferecimento de medicamentos, exames, consultas, procedimentos cirúrgicos etc.

No caso, após novamente examinar os autos, concluo que o pedido inicial deve ser julgado procedente, pois comprovada a necessidade da alimentação especial para o caso específico da Autora, como foi observado, aliás, pelo E. Tribunal de Justiça na decisão que concedeu a tutela provisória.

A Requerente, criança hoje com oito anos de idade (f. 18), necessita do leite especial para sua melhor recuperação, manutenção de peso e estado nutricional, como foi indicado por Nutricionista à f. 21 e conforme consta da prescrição médica de f. 20 com o seguinte teor:

> *"Declaro que a paciente Ana Luíza Lima Moreira necessita uso de Nutren Júnior para manutenção do peso e estado nutricional, aproximadamente 20 latas (400g) por mês.*
> *Paciente de 7 anos, com paralisia cerebral secundária à prematuridade, pneumonias de repetição com gastrostomia há 4 anos."*

Como observado em segunda instância, a criança vem sendo atendida pelo SUS, cujos médicos têm conhecimento das recomendações existentes no âmbito da rede pública e se estas pudessem ser aplicada à Requerente, certamente o teriam feito.

Trata-se, como se vê, de criança de tenra idade acometida com problemas de saúde e sob risco de desnutrição se não receber a alimentação adequada e prescrita. E se a genitora da Autora não tem condições financeiras de adquirir tal alimentação, a Requerente não poderá ficar desassistida e à míngua.

Não se olvide, ademais, que a criança é dotada de especial proteção do Estado, a quem deve ser garantido o melhor interesse, como determina o art. 227 da Constituição Federal:

> *Art. 227. É **dever** da família, da sociedade e **do Estado assegurar à criança**, **ao adolescente** e ao jovem, **com absoluta prioridade**, **o direito à vida, à saúde, à alimentação**, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.(*Grifei)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 12/11/2019 às 11:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807989-97.2018.8.12.0029 e código rhJBqIFX.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

A pretensão da Autora encontra amparo no próprio texto constitucional e deve ser assegurada da melhor maneira possível.

Não há falar que o atendimento somente deverá ser fornecido quando houver risco de morte, pois a Constituição garante a saúde em suas mais variadas acepções, inclusive como um processo de "bem-estar" geral ou social. É evidente que todos têm o direito de viver de forma digna e com saúde, o que está intrinsecamente ligado à garantia de recebimento de atendimento adequado pelo serviço universal e integral que deve ser prestado pelo Estado em suas diversas esferas.

Não se trata de judicializar políticas públicas, mas de garantir o atendimento adequado a quem dele necessita. É fazer com que o Estado (sentido amplo) cumpra seu papel, cumpra as políticas públicas com as quais deveria estar comprometido, cumpra os fins do Estado estabelecidos na Constituição.

No que toca à imposição de multa, é ela perfeitamente possível, conforme reiteradamente os tribunais superiores têm decidido, não tendo a Fazenda Pública prerrogativa de não se sujeitar a referida técnica executiva.

Quanto ao pagamento das custas processuais, que não se confundem com a multa, como cediço, os entes públicos são isentos de seu pagamento.

Em relação aos honorários advocatícios, tem-se que no presente caso é incabível condenar o Estado ao pagamento de tal verba em favor da Defensoria Pública, nos termos da Súmula 421 do STJ, que assim dispõe:

> *"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".*

Dessa maneira, ocorreria confusão se houvesse condenação do Estado de Mato Grosso do Sul a pagar honorários à Defensoria Pública que é por si mantida.

Ante o exposto, confirmando neste momento a tutela provisória concedida em segundo grau, **JULGO PROCEDENTE** o pedido que **Ana Luiza Lima Moreira** fez em desfavor do **Estado de Mato Grosso do Sul** e do **Município de Naviraí**, qualificados, para o fim de determinar aos Réus que forneçam à Autora, por meio de seus órgãos executores competentes, **20(vinte) latas ao mês do leite especial Nutren Júnior,** num prazo não superior a **10 (dez) dias**, **a contar da intimação, renovando-se a obrigação automaticamente mês a mês a partir da mesma data enquanto perdurar a necessidade da Autora, sob pena de incorrerem em multa de R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitada inicialmente a 30(trinta) dias.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 12/11/2019 às 11:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807989-97.2018.8.12.0029 e código rhJBqIFX.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

Sem custas, *ex vi legis*.

Condeno tão somente o réu Município de Naviraí ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que fixo em R$500,00(quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, já considerado o grau de zelo do profissional, a importância e a natureza da causa, o tempo e o lugar da prestação do serviço.

Declaro **extinto** o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sentença sujeita a reexame, pois a obrigação é de valor incerto e ilíquido. Assim, decorrido o prazo para interposição de recurso, remeta-se o feito ao E. TJMS para reapreciação.

Havendo o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades.

P.R.I.C.

Naviraí/MS, **datado e assinado digitalmente.**

Eduardo Magrinelli Júnior
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 12/11/2019 às 11:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0807989-97.2018.8.12.0029 e código rhJBqIFX.